

1500088-84.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... de crack. Tem passagens por furto e tráfico. Quer ser réu confesso. Foi ele quem entrou. Saiu dia 03 de agosto, teve uma recaída. Ficou 3, 4 semanas na rua, usuário de crack, viu ali um jeito de conseguir mais droga. Precisava de dinheiro para saldar sua dívida e para usar. Bebe cachaça também. Estava no posto bebendo água quando foi abordado. O policial já o conhece, por isso foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500088-84.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500088-84.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2013586/2022 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 22464565 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 363/22/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2013586 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2013586/2022 - Delegacia Seccional de Taubaté, 2013586 - CPJ TAUBATÉ, 363/22/516 - CPJ TAUBATÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEKISSILEI DAMASCENO DA FONSECA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

WEKISSILEI DAMASCENO DA FONSECA, qualificado nos autos às fls. 08, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e II, do Código Penal, sob a acusação de que, na madrugada de 15 de janeiro do ano de 2022, portanto durante período de repouso noturno, em horário não determinado, na Travessa Rafael nº 91/97, centro, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, em detrimento do estabelecimento comercial Ferrari Júnior Imóveis, pertencente a Vitor Câmara Viviane dos Santos (fls. 05), além da importância - em dinheiro - de R\$ 475,00, seis aparelhos de telefone celular e um notebook que, relacionados e avaliados no auto acostado às fls. 34, totalizaram o valor estimado de R\$ 1.250,00.

Consta na denúncia que a subtração supramencionada foi perpetrada mediante escalada e rompimento de obstáculo. De feito. Pleno de resolução criminoso, visando ao ilícito assenhoreamento e aproveitando-se do lóbrego noturno, da solitude e quietude proporcionadas pelo adiantado do horário, bem como do fato de encontrar-se desocupado o estabelecimento porque já ultrapassado o período comercial, o réu,

inicialmente, galgou o muro ou paredes que circundavam os perímetros do prédio para, assim, chegar ao telhado da construção, onde removeu e fraturou telhas para abrir vão que permitisse a passagem de seu corpo e seu acesso ao interior do imóvel. Ato contínuo, por meio do rompimento da estrutura do forro de gesso do teto do prédio, possivelmente utilizando-se de instrumento não apreendido, o réu adentrou as dependências da casa comercial e ali apoderou-se dos bens alheios, que acondicionou numa sacola e levou consigo, os quais, entretanto, momentos após, foram apreendidos ulteriormente em poder do réu, mas por mera casualidade, por policiais militares em patrulhamento de rotina em outro ponto da urbe (na Avenida José Vicente de Faria Lima, no Bairro Vila São José).

A prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva por decisão plantonista (fls. 55/56 e 92/94).

A denúncia (fls. 75/76) foi recebida em 19 de janeiro de 2022 (fls. 80/83).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 95) e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 98/99).

Em instrução, ouviram-se a vítima, duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, diante da prova colhida. Réu reincidente, regime fechado. Inviabilizada a substituição da pena.

Já a Defesa, por sua vez, diante da confissão, reiterou em parte a manifestação ministerial, mas entendeu que a confissão deva ser compensada com a reincidência e ser possível o regime intermediário.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva estatal merece total acolhimento, pois ficou comprovado que o réu cometeu o delito, conforme descrito na inicial acusatória.

A materialidade do crime ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/44), pela fotografia do réu (fls. 11), pelo boletim de ocorrência (fls. 29/31), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 32), pela fotografia dos itens apreendidos (fls. 33), pelo auto de avaliação (fls. 34), pelo auto de entrega (fls. 35), pelo laudo do exame cautelar de lesão corporal realizado no réu, que não constatou lesões corporais recentes de interesse médico-legal (fls. 37), pelo laudo da perícia realizada no local dos fatos, verificando que "o acesso ao interior do imóvel se deu por superação da altura da vedação externa do imóvel 91/97, na fachada voltada para a Rua do Corrêa, porção vizinha ao imóvel 291 daquela via, com possível utilização do pequeno gradil metálico de vedação frontal do imóvel 291 e do elemento de decoração do imóvel periciado na forma de improvisada como 'escada', com acesso total e irrestrito a cobertura do imóvel periciado; bem assim por meio de remoção de telha(s) de fibrocimento com consequente abertura de vão entre as telhas, aliado a constatada danificação por fratura total e fragmentação do forro em gesso, com consequente abertura de vão no forro, obtido acesso total e irrestrito ao interior do imóvel periciado, remanescendo as marcas de sujidades e esfregações de sujidades de manipulações e pegadas nas paredes anterior e direita no ambiente da cozinha do imóvel vítima" (fls. 166/184) e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, igualmente é certa.

O réu, na delegacia (fls. 06), declarou "QUE dispensa a assistência de Advogado para este ato e, afirma não dispor de recursos para custear um defensor, razão pela qual requer lhe seja concedido um defensor público; afirma não desejar que seus familiares sejam cientificados de sua prisão; afirma possuir passagens criminais pretéritas por infração aos artigos 155, artigo 157 do Código penal e artigo 33 da Lei 11343/06; afirma ser solteiro e possuir quatro filhos os quais residem com a própria genitora; afirma ser dependente químico de drogas, em especial CRACK; quanto aos fatos ora apurados afirma que passava na Avenida Juca Esteves, nessa cidade e, que defronte a escola denominada Microcamp há uma caçamba de coleta de entulhos e, parou para ver o que havia dentro, constatando que havia um notebook, o qual tentou ligar e não funcionou, encontrou também alguns telefones celulares, dos

quais apenas um funcionava e, ainda achou uma bolsinha que continha dinheiro em seu interior, razão pela qual, recolheu os objetos e os colocou dentro de uma sacola plástica que também estava no interior da caçamba e, em seguida retornava para sua residência quando foi abordado por policiais militares, os quais lhe indagaram a origem de tais objetos, sendo que prontamente informou o já noticiado e, através do telefone celular que funcionava, um dos policiais realizou algumas ligações e afirmou que tal telefone era furtado, tornando a explicar para os policiais que apenas encontrara os objetos, negando tê-los furtado." (sic).

Ele não foi ouvido em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n. 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Em juízo o réu disse que tem 40 anos, trabalhava como ajudante geral, mas estava parado há 3, 4 semanas. É usuário de crack. Tem passagens por furto e tráfico. Quer ser réu confesso. Foi ele quem entrou. Saiu dia 03 de agosto, teve uma recaída. Ficou 3, 4 semanas na rua, usuário de crack, viu ali um jeito de conseguir mais droga. Precisava de dinheiro para saldar sua dívida e para usar. Bebe cachaça também. Estava no posto bebendo água quando foi abordado. O policial já o conhece, por isso foi abordado. Negou, ninguém quer ser preso. Tinha vários celulares, um só funcionava e um notebook que não estava ligando. Dinheiro não tinha. Escalou um suporte de ferro de enfeite. Alcançou o telhado, quebrou uma ponta que estava solta, entrou e viu que era teto de gesso, também quebrou um pedaço para entrar. O primeiro policial ouvido o persegue.

O representante da empresa vítima, na delegacia (fls. 05), relatou que "é Auxiliar Administrativo do estabelecimento denominado FERRARI JÚNIOR IMÓVEIS, estabelecido na Travessa Rafael nº. 91 e 97, Centro dessa cidade; afirma ter sido contatado por telefone pela funcionária BRUNA LETÍCIA, a qual noticiava que um cliente da imobiliária havia sido contatada pela polícia militar pois, haviam detido um homem o qual estava na posse de um telefone de aparelho celular de uso da imobiliária, razão pela qual solicitavam, o comparecimento do declarante nesse plantão policial para proceder o reconhecimento dos objetos, razão pela qual, imediatamente se dirigiu para este plantão e, ao chegar viu que os policiais ainda não haviam chegado, razão pela qual se dirigiu para a imobiliária, onde localizou os policiais militares custodiando a pessoa que viu e, neste plantão policial afirma se tratar da pessoa identificada como sendo WEKISSILEI DAMASCENO DA FONSECA e, ainda, lhe foi exibido uma pequena necesser de material sintético plástico branco contendo em seu interior a quantia de R\$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), o aparelho de telefone celular da marca MOTOROLA em funcionamento; três aparelhos de telefone celular da marca motorola, todos antigos e desativado; dois aparelhos de telefone celular, sendo um da marca NOKIA e outro da marca NEXTEL, ambos antigos e desativados e, ainda, um notebook da marca POSITIVO, modelo SIM, os quais estavam na posse da pessoa de WEKISSILEI DAMASCENO DA FONSECA, objetos estes que foram PRONTAMENTE RECONHECIDOS pelo declarante como sendo de propriedade da imobiliária e, ainda pode verificar que a pessoa de WEKISSILEI DAMASCENO DA FONSECA acessou o interior da imobiliária pelo telhado, chegando a quebrar o gesso do forro do refeitório." (sic).

Em juízo o representante da vítima, Vítor, disse que acordou com uma ligação de uma funcionária da imobiliária, porque um cliente da imobiliária avisou que tinham entrado na imobiliária e tinha polícia lá, pedindo para ir ao local. Ao chegar na imobiliária, o rapaz já estava dentro da viatura. Reconheceu o celular. Estava tudo virado lá dentro. Na cozinha havia um buraco no forro de gesso. Tinha cerca de 400 reais em dinheiro, um notebook e celulares que ele levou. Perguntou para o policial, o réu teria dito para ele que encontrou na rua.

As testemunhas Clóvis e Kleber, Policiais Militares, na delegacia (fls. 02 e 04), relataram "que, realizavam deslocamento para o atendimento de uma ocorrência quando ao trafegarem pela Avenida José Vicente de Faria Lima, Vila São José, nesta cidade, avistaram a pessoa que mais tarde foi identificada como sendo WEKISSILEI DAMASCENO DA FONSECA, correndo em carregando consigo uma sacola plástica, conduta que pareceu suspeita, razão pela qual procederam a abordagem de tal pessoa e constataram que no interior da sacola plástica que este carregava havia um Notebook da marca POSITIVO, um aparelho de telefone celular da marca MOTOROLA, o qual se encontrava com

bateria carregada e funcionando, outros três aparelhos de telefone celular da marca MOTOROLA, todos antigos e sem funcionamento, um telefone celular da marca NEXTEL e um aparelho de telefone celular da marca NOKIA, ambos antigos e sem funcionamento e, ainda, uma necesser de cor branca contendo em seu interior a quantia de R\$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais); afirmando que teria encontrado tais objetos no interior de uma caçamba tira entulho, nas proximidades da escola Microcamp e, diante dos fatos, examinaram o telefone celular da marca MOTOROLA que se encontrava em funcionamento, através do qual realizaram ligação para um dos contatos o qual noticiou que reconhecia o número telefônico como sendo da imobiliária FERRARI JÚNIOR IMÓVEIS, do qual era cliente e que faria contato com os proprietários e, diante dos fatos se dirigiram para a imobiliária indicada como sendo estabelecida na Travessa Rafael nº. 91 e 97, onde mais tarde se fez presente a pessoa de VITOR CÂMARA VIVIANI DOS SANTOS, o qual reconheceu os objetos localizados e apreendidos como sendo da imobiliária e, ainda, acompanhou a fiscalização do imóvel onde foi constatado a invasão por meio do telhado do refeitório, fatos e motivos pelos quais, foi dado voz de prisão para a pessoa de WEKISSILEI DAMASCENO DA FONSECA" (sic).

Em juízo o policial Kleber declarou que viram um individuo correndo na via com uma sacola na mão. Suspeitaram e abordaram-no. Ele foi resistente a abordagem.

Precisaram usar força para contê-lo. Na sacola havia um notebook, uma necessaire com celulares, um deles em funcionamento, com abertura de tela de uma imobiliária. De fora não viram arrombamento na imobiliária. Fizeram contato com alguém no celular. Foi difícil por causa do horário. A pessoa falou com o proprietário, que mandou um funcionário ao local. Ele constatou o arrombamento no telhado do refeitório e constatou que sem dúvida os pertences eram da imobiliária. O réu disse que achou numa caçamba. O local da abordagem é distante do local do furto, mais de 500 metros.

Em juízo o policial Clóvis declarou que se depararam o réu correndo com uma sacola na mão e o abordaram. A sacola continham notebook, aparelhos celulares, uma bolsa com dinheiro, 475 reais. Ele disse que achou em uma caçamba de entulho. Começaram a averiguar os celulares, um deles funcionava. Havia fotos de imóveis, telefones de contato, era de uma imobiliária, através de um contato fizeram contato com um cliente da imobiliária que entrou em contato com uma pessoa da imobiliária. Foram até a imobiliária, que é um local bem fechado. Não tinham percebido nenhum tipo de arrombamento, é bem alto. O representante da imobiliária identificou de pronto o notebook, os celulares e o dinheiro. Abriu a imobiliária. No fundo tem um refeitório e no teto o forro de gesso estava danificado e removido. Foi por onde ele adentrou.

Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu praticou o delito descrito na inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

Na data dos fatos, o réu, contaminado pelo animus criminoso, deliberou por furtar o estabelecimento vítima e, para tanto, aproveitando-se do fato de já ter anoitecido - e, portanto, contar com o ambiente já escuro -, escalou a lateral do imóvel, alcançando o telhado, danificou o forro de gesso do refeitório e adentrou no local. Já no interior do estabelecimento, ele selecionou os objetos que mais o interessavam, quais sejam, R\$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) em dinheiro, um notebook, um telefone celular da marca Motorola em condições de uso e outros cinco aparelhos celulares antigos de marcas diversas, que estavam desativados.

Em seguida, o réu deixou o local, na posse dos objetos furtados.

Algum tempo depois, policiais militares estavam em deslocamento para atender uma ocorrência diversa, quando então se depararam com o réu em atitude suspeita na via pública. Tal atitude suspeita se justificativa porque ele corria enquanto carregava uma sacola plástica, circunstância que ensejou a abordagem.

Os policiais revistaram a sacola que ele trazia consigo, prontamente localizando os objetos supramencionados, que haviam sido furtados do estabelecimento vítima momentos antes.

Informalmente inquirido acerca da procedência dos objetos, o réu disse que havia os encontrado em uma caçamba, nas proximidades de uma escola.

Considerando as circunstâncias, os policiais desconfiaram de suas alegações, razão pela qual utilizaram o único telefone celular que funcionava e ligaram para um dos contatos salvos no aparelho. Nessa ocasião, a pessoa que atendeu relatou ser cliente do estabelecimento vítima e informou que o número pertencia ao estabelecimento.

Formalmente inquirido pela Autoridade Policial, o réu declarou ser dependente químico e manteve a versão de que encontrou os objetos que trazia consigo em uma caçamba de coleta de entulhos, negando ter furtado os objetos.

Em juízo, o réu confessou ter praticado a subtração. Admitiu, inclusive, que o furto foi cometido mediante escalada e rompimento de obstáculo.

Como consabido, a confissão evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como no caso em comento.

Com efeito, "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112).

A autoria delitiva é, portanto, inconteste.

Além de ser encontrado em posse da res, o réu admitiu em juízo a prática do crime, com todos os detalhes que foram constatados pela perícia realizada no local.

Está claro que o delito se consumou, pois o réu teve a posse desvigiada da res.

Como consabido, o crime de furto aperfeiçoa-se quando ocorre a inversão da posse da res pelo agente, conferindo-lhe a tranquila detenção da coisa, ainda que por curto espaço de tempo, longe da área de vigilância do espoliado (RJDTACRIM 28/323).

Ressalte-se que a subtração se deu durante a madrugada, de modo que a causa de aumento do repouso noturno, inculpada no artigo 155, §1º, do Código Penal, deve ser reconhecida, porque está narrada na exordial e provada na instrução criminal.

É inegável o fato de que o réu se valeu do lôbrego noturno e da menor vigilância comum em razão do avançado da hora para obter êxito na empreitada criminosa.

A razão da majorante liga-se ao maior perigo a que é submetido o bem jurídico diante da precariedade de vigilância por parte de seu titular, durante a noite.

Assim decide o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Nos presentes autos se discute a possibilidade de aplicação da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal aos crimes de furto simples praticado em estabelecimento comercial durante o período de repouso noturno. O legislador, ao inserir o §1º do art. 155 no Código Penal, visou suprir a deficiência da segurança durante o período de ausência da luz solar. Nesses termos, tinha como intenção resguardar o patrimônio de forma geral, não fazendo diferenciação entre o patrimônio da pessoa física e o da jurídica, já que ambas podem ser sujeito passivo do crime de furto. (...) Assim, reputo irretocável a decisão formalizada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo regimental, porquanto o repouso noturno deve ser considerado nas hipóteses de furto praticado em estabelecimento comercial, tendo em vista a maior probabilidade do agente lograr êxito em virtude da menor vigilância sobre o bem. Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem." (HC 132993/DF, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 15/09/2016 - destaquei).

"Apelação. Furto majorado pelo repouso noturno. Art. 155, §1º, do CP. Tese de tentativa afastada. Teoria da Amotio. Majorante do repouso noturno que se aplica mesmo para estabelecimentos comerciais e casas desabitadas, em razão da maior vulnerabilidade do patrimônio no horário de repouso geral. Impossibilidade de alteração do regime inicial fechado. Súmula nº 269 do C. STJ que traz permissivo, não comando obrigatório. Existência de maus antecedentes. Sentença mantida. Recurso não provido" (TJSP; Apelação 0000605-06.2017.8.26.0630; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de Registro: 12/08/2018 - destaquei).

Assim, devidamente comprovado que o delito foi cometido durante o repouso noturno,

de rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal.

Também configuradas as qualificadoras previstas no artigo 155, §4º, inciso I e II, do Código Penal, pois ficou demonstrado nos autos que o réu, para adentrar o estabelecimento vítima, escalou parede e adereço do imóvel e danificou telhas e o forro de gesso do refeitório, rompendo, portanto, o obstáculo que impedia a entrada no local.

Neste sentido, além da confissão do acusado, o laudo da perícia realizada no local constatou "o acesso ao interior do imóvel se deu por superação da altura da vedação externa do imóvel 91/97, na fachada voltada para a Rua do Corrêa, porção vizinha ao imóvel 291 daquela via, com possível utilização do pequeno gradil metálico de vedação frontal do imóvel 291 e do elemento de decoração do imóvel periciado na forma de improvisada como 'escada', com acesso total e irrestrito a cobertura do imóvel periciado; bem assim por meio de remoção de telha(s) de fibrocimento com consequente abertura de vão entre as telhas, aliado a constatada danificação por fratura total e fragmentação do forro em gesso, com consequente abertura de vão no forro, obtido acesso total e irrestrito ao interior do imóvel periciado, remanescendo as marcas de sujidades e esfregaços de sujidades de manipulações e pegadas nas paredes anterior e direita no ambiente da cozinha do imóvel vítima" (fls. 166/184).

O réu admitiu que realmente escalou um suporte de ferro de enfeite para alcançar o telhado, removeu telhas e danificou o forro.

Com relação à possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno aos furtos qualificados, entendo serem plenamente compatíveis entre si, conforme consolidada jurisprudência.

Assim entende o Supremo Tribunal Federal:

"Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, §4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada." (STF, HC n. 130.952/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 13/12/2016 - destaquei).

Impossível o reconhecimento do privilégio insculpido no artigo 155, §2º, do Código Penal, porquanto a soma do numerário furtado em dinheiro com o valor dos bens surrupiados superam o valor do salário-mínimo, conforme auto de avaliação de fls. 34, parâmetro jurisprudencial para a mensurar o "pequeno valor" trazido pelo texto legal.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Para a caracterização do furto privilegiado, além da primariedade do réu, o valor do bem subtraído não deve exceder à importância correspondente ao salário mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1525563/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/09/2015; AgRg no REsp 1486001/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 05/05/2015; AgRg no REsp 1447688/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/02/2015; HC 282268/RS, Rel. Ministro Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC), Quinta Turma, julgado em 04/12/2014; HC 217726/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/04/2014; AgRg no

REsp 1112778/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 19/09/2013; AgRg no HC 246338/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 05/02/2013; AgRg no REsp 1278756/SP, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), julgado em 09/10/2012; HC 179580/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 26/10/2010). Além disso, trata-se de réu reincidente, o que também obsta a aplicação do furto privilegiado.

Nesta toada, deverá o réu responder pelo delito tipificado no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e II, do Código Penal.

Passo a aplicar a pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, considerando que o réu ostenta antecedentes desabonadores também em delitos patrimoniais (processo de conhecimento n.º 12797/2011, desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, execução nº 1, de nº 7002005-24.2012.8.26.0625, às fls. 127, cuja extinção da punibilidade se deu ante a concessão de indulto em 10/03/2017, conforme fls. 125; processo de conhecimento nº 0014928-07.2012.8.26.0625, da 3ª Vara Criminal de Taubaté, execução nº 2, de nº 7003834-69.2014.8.26.0625, às fls. 127, cuja extinção da punibilidade pelo cumprimento se deu em 19/05/2017, conforme fls. 126), bem como se levando em consideração que, no momento do delito, estava sendo agraciado com o benefício do livramento condicional, de acordo com as informações extraídas dos documentos de fls. 48/49, fato que demonstra que a conduta social do réu é mais reprovável, pois evidencia seu caráter desvirtuado, um verdadeiro comportamento social inadequado, descomprometido com o cumprimento da ordem e da lei, e ainda se levando em consideração a existência de duas qualificadoras do delito (rompimento de obstáculo e escalada), sendo uma utilizada para modificar a pena inicial e a outra que demonstra maior culpabilidade na conduta do réu a ensejar maior reprovabilidade, fixo a pena-base em 1/4 acima do mínimo legal, para que fique em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Sobre a exasperação da pena em relação às qualificadoras:

“A pena não comporta reparos: base fixada em ¼ (um quarto) acima do mínimo legal, pela consideração da segunda e terceira qualificadoras como circunstâncias judiciais de exasperação, e, em seguida, tornada definitiva, à míngua de agravantes e de causas especiais de diminuição e de aumento. E não há se falar em bis in idem na hipótese, visto que, havendo três qualificadoras, uma efetivamente qualifica o delito, enquanto as outras podem ser utilizadas para exasperar a pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal.” (Apelação nº 0000036-89.2008.8.26.0025 - 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 13 de dezembro de 2012, Relator Louri Barbiero).

No mesmo sentido, ensina a doutrina: “Concurso de qualificadoras. Previstas no mesmo tipo penal, aplica-se uma só, servindo a outra de circunstância judicial de agravação de pena. Havendo duas circunstâncias, a segunda qualificadora deve ser considerada como circunstância judicial de exasperação da pena, nos termos do art. 59, caput, do Código Penal, ingressando na expressão circunstância empregada no texto” (Damásio E. de Jesus, Código Penal Anotado, Ed. Saraiva, 18ª. Edição, pág. 251).

A valoração negativa da conduta social do réu se encontra em plena consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL COMO VETORIAL NEGATIVA. LEGALIDADE. DELITO PRATICADO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DA PROGRESSÃO DE REGIME PELO COMETIMENTO DE CRIME ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n.º 556.444/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 18/08/2020).

Trata-se de réu reincidente (processo de conhecimento n.º 0014561-75.2015.8.26.0625, desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 49/50, com processo de execução de nº 0004167-32.2016.8.26.0509, no qual foi concedido livramento

condicional em 03/08/2021, conforme fls. 48/49), circunstância que denota maior descaso com a Justiça e a habitualidade da prática delitiva, motivo pelo qual agravo a pena em 1/5, para que passe a ser 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea, compenso-a com a agravante da reincidência, para que a pena retorne ao quanto fixado na primeira fase da dosimetria, ficando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Sobre a compensação: "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. NOTÓRIO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE. ROUBO. CÁLCULO DA PENA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. Quando se trata de notório dissídio jurisprudencial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que devem ser mitigados os requisitos formais de admissibilidade concernentes aos embargos de divergência. Precedentes. 2. É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. 3. Embargos de divergência acolhidos para restabelecer, no ponto, o acórdão proferido pelo Tribunal local." (STJ. EResp n. 1.154.752/RS, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, j. em 23/05/2012 - destaquei).

Tendo em vista que o delito foi cometido durante o repouso noturno, diminuindo a vigilância sobre a res furtiva, com fundamento no artigo 155, §1º, do Código Penal, aumento a pena em 1/3, para que fique em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

À vista dos elementos dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos contidos no artigo 44, inciso II e §3º, do Código Penal, pois o réu é reincidente específico em crimes contra o patrimônio. Pela mesma razão, o réu não faz jus ao sursis (art. 77, inciso I, do Código Penal).

Em razão da reincidência, o réu iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Neste sentido: "REGIME PRISIONAL - Determinação inicial - Aberto - Inadmissibilidade - Ré reincidente - Início do cumprimento da pena no regime imediatamente mais rigoroso do que aquele previsto para réu primário - Inteligência do artigo 33 e §§ do Código Penal - Fixação do regime semi-aberto (artigo 33, caput, e § 2º, c, do Código Penal) - Recurso provido" (TJSP - Apelação Criminal n.º 266.275-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 30.12.98 - V.U.).

Ainda que se tenha que levar em consideração a detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para a fixação do regime inicial, neste caso, não haverá qualquer modificação fática, porquanto o réu é reincidente e o regime inicial para o cumprimento de sua pena continua sendo o semiaberto.

Não bastasse, estava sendo beneficiado por livramento condicional quando cometeu este delito, devendo eventual progressão de regime ser verificado pelo juízo das execuções.

Com efeito, ainda que se entenda que o sentido da norma vai além da detração do tempo de prisão preventiva para fim de regime inicial, nos termos do artigo 33 do Código Penal, seria temerário apreciar-se benefícios a cargo do juiz da execução quando se tem outras execuções em curso, benefícios a serem considerados, condenações definitivas, penas a serem cumpridas.

Nesta toada, não concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou decretação da prisão preventiva, bem como pelo quantum de pena aplicada e o regime inicial do cumprimento da sanção corporal e sua espécie, pois o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente - precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014.



Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Não bastasse o sobredito posicionamento, com a prolação da presente sentença condenatória em cognição exauriente (após o exercício da ampla defesa e do contraditório), há inegável reconhecimento judicial da autoria e materialidade delitivas. Consequentemente, a custódia cautelar é a única medida possível para garantia da ordem pública. Pontue-se também que restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do sentenciado, na medida em que ele se dedicava às atividades espúrias.

Acresça-se que, em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ. Assim, inexistindo prejuízos ao sentenciado quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019), não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Tendo em vista a fundamentada revisão, registro a interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR WEKISSILEI DAMASCENO DA FONSECA, filho de Pedro Damasceno da Fonseca e Maria Aparecida Damasceno da Fonseca, RG n.º 32.236.834, nascido aos 06 de agosto de 1981, natural de Taubaté/SP, como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e II, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Recomenda-se a manutenção do réu onde se encontra recolhido em razão da sentença condenatória.

Expeça-se a respectiva Guia de Recolhimento Provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Ante a manutenção do réu no cárcere, deverá a Serventia inserir um alerta no Sistema Informatizado, para que se possibilite o controle do prazo de 85 (oitenta e cinco) dias, indicado no Comunicado CG n. 78/2020, bem como deverá encaminhar cópia deste feito à fila “acompanhamento de preventiva decretada”, para eventual apreciação, se os autos ainda estiverem em primeiro grau.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Tendo em vista que o réu estava sendo beneficiado pelo benefício do livramento condicional quando cometeu este crime, encaminhem-se certidão de objeto e pé a 2ª Vara das Execuções Criminais de Taubaté, para que instrua os autos do processo de execução criminal n.º 0004167-32.2016.8.26.0509.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

P.R.I.C. Oportunamente, ao arquivo.

Taubaté, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA